

予備独自問題 H28-21

(配点：2)

月 日

月 日

次の【記述】は、訴因変更の要否に関する最高裁判所の決定からの引用である。【記述】中の①から④までの()内から適切な語句を選んだ場合、その組合せとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。

【記述】

殺人罪の共同正犯の訴因としては、その実行行為者がだれであるかが明示されていないからといって、それだけで直ちに訴因の記載として罪となるべき事実の特定に欠けるものとはいえないと考えられるから、訴因において実行行為者が明示された場合にそれと異なる認定をするとしても、①(a. 審判対象の画定 b. 被告人の防御)という見地からは、訴因変更が必要となるとはいえないものと解される。とはいえ、実行行為者がだれであるかは、一般的に、②(a. 審判対象の画定 b. 被告人の防御)にとって重要な事項であるから、当該訴因の成否について争いがある場合等においては、③(a. 他の犯罪事実との識別 b. 争点の明確化)などのため、検察官において実行行為者を明示するのが望ましいということができ、検察官が訴因においてその実行行為者の明示をした以上、判決においてそれと実質的に異なる認定をするには、原則として、訴因変更手続を要するものと解するのが相当である。しかしながら、実行行為者の明示は、前記のとおり訴因の記載として不可欠な事項ではないから、少なくとも、被告人の防御の具体的な状況等の審理の経過に照らし、④(a. 被告人に不意打ちを与えるものではない b. 他の犯罪事実との識別を損なうものではない)と認められ、かつ、判決で認定される事実が訴因に記載された事実と比べて被告人にとってより不利益であるとはいえない場合には、例外的に、訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる実行行為者を認定することも違法ではないものと解すべきである。

1. ①a ②b ③a ④a
2. ①a ②b ③b ④a
3. ①a ②b ③b ④b
4. ①b ②a ③a ④a
5. ①b ②a ③a ④b

完成全文

殺人罪の共同正犯の訴因としては、その実行行為者がだれであるかが明示されていないからといって、それだけで直ちに訴因の記載として罪となるべき事実の特定に欠けるものとはいえないと考えられるから、訴因において実行行為者が明示された場合にそれと異なる認定ををするとしても、①(a. 審判対象の画定)という見地からは、訴因変更が必要となるとはいえないものと解される。とはいえ、実行行為者がだれであるかは、一般的に、②(b. 被告人の防御)にとって重要な事項であるから、当該訴因の成否について争いがある場合等においては、③(b. 争点の明確化)などのため、検察官において実行行為者を明示するのが望ましいということができ、検察官が訴因においてその実行行為者の明示をした以上、判決においてそれと実質的に異なる認定をするには、原則として、訴因変更手続を要するものと解するのが相当である。しかしながら、実行行為者の明示は、前記のとおり訴因の記載として不可欠な事項ではないから、少なくとも、被告人の防御の具体的な状況等の審理の経過に照らし、④(a. 被告人に不意打ちを与えるものではない)と認められ、かつ、判決で認定される事実が訴因に記載された事実と比べて被告人にとってより不利益であるとはいえない場合には、例外的に、訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる実行行為者を認定することも違法ではないものと解すべきである。

() には、順に「①a ②b ③b ④a」が入り、したがって、正解は肢2となる。

【記述】は、訴因変更の要否に関する最決平13.4.11(百選46事件)からの引用である。

①について

判例は、第1段階として、「殺人罪の共同正犯の訴因としては、その実行行為者がだれであるかが明示されていないからといって、それだけで直ちに訴因の記載として罪となるべき事実の特定に欠けるものとはいえないと考えられるから、訴因において実行行為者が明示された場合にそれと異なる認定ををするとしても、審判対象の画定という見地からは、訴因変更が必要となるとはいえない」としている。これは、訴因の機能としては審判対象の画定と被告人の防御権の保障という2点があり、一般的に訴因変更の要否を判断する場合には、まずその事項が審判対象を画定するのに必要な事項か否かを検討すべきとしているものと解されている。なぜなら、訴因の設定の場面における訴因の第一次的な機能は、検察官が裁判所に対し審判対象たる「罪となるべき事実」を特定することにあることから、訴因変更の要否も一次的には「審判対象の画定」という観点から検討することが整合的だと考えられているからである。したがって、①には「a. 審判対象の画定」が入る。

②③について

判例は、第2段階として、「実行行為者がだれであるかは、一般的に、被告人の防御にとって重要な事項であるから、当該訴因の成否について争いがある場合等においては、争点の明確化などのため、検察官において実行行為者を明示するのが望ましいということができ、検察官が訴因においてその実行行為者の明示をした以上、判決においてそれと実質的に異なる認定をするには、原則として、訴因変更手続を要する」としている。これは、審判対象の画定の見地からは訴因変更の必要がない場合であっても、被告人の防御権の保障の見地から訴因変更が必要となることがあり得るとしたものである。そして、被告人の防御にとって重要な事項については、原則として訴因変更の必要な場合があり、共

同正犯における実行行為者の特定は訴因にあげられた以上それに該当するとしている。したがって、②には「b. 被告人の防御」が入る。また、③「a. 他の犯罪事実との識別」は、「罪となるべき事実の特定」の問題であり、審判対象の画定に対応する語句である。他方、③「b. 争点の明確化」は、被告人の防御に対応する語句である。したがって、③には「b. 争点の明確化」が入る。

④について

判例は、第3段階として「実行行為者の明示は、前記のとおり訴因の記載として不可欠な事項ではないから、少なくとも、被告人の防御の具体的な状況等の審理の経過に照らし、被告人に不意打ちを与えるものではないと認められ、かつ、判決で認定される事実が訴因に記載された事実と比べて被告人にとってより不利益であるとはいえない場合には、例外的に、訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる実行行為者を認定することも違法ではない」としている。訴因変更は、基本的には抽象的・一般的に判断すべきであり、一般的には、訴因変更等の手続によって、不意打ち防止を図るのが望ましい。もっとも、具体的な訴訟の経緯に応じて個別に判断し、結果として不意打ちが防止できれば必ずしもかかる手続による必要はない。したがって、④には「a. 被告人に不意打ちを与えるものではない」が入る。

